AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5028197-03.2015.4.04.0000/RS

RELATOR	:	**ROGERIO FAVRETO**
AGRAVANTE	:	**RAFAEL BELLINCANTA (Absolutamente Incapaz (Art. 3º, II e III CC))**
	:	**MARTA BELLINCANTA DOS SANTOS (Pais)**
ADVOGADO	:	**LEANDRO GUILHERME SIGNORINI**
AGRAVADO	:	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
MPF	:	**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. **BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAL**. RESTABELECIMENTO. REQUISITO ECONÔMICO. RENDA PER CAPITA INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. CRITÉRIO INCONSTITUCIONAL. VEROSSIMILHANÇA. **ANTECIPAÇÃO DE TUTELA**. CONCESSÃO.

Afigura-se arbitrária a cessação administrativa de **benefício assistencial** de pessoa incapaz com base tão somente no fato da renda *per capita* da família superar o equivalente a ¼ do salário mínimo.

Demonstradas a verossimilhança e a urgência necessárias a justificar o regime excepcional da antecipação da tutela jurisdicional, é de ser provido o **recurso** para se determinar o imediato restabelecimento do benefício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 5a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 10 de novembro de 2015.

Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7757606v3** e, se solicitado, do código CRC **93E59E65**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Rogerio Favreto
Data e Hora: 12/11/2015 13:26

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5028197-03.2015.4.04.0000/RS

RELATOR	**:**	**ROGERIO FAVRETO**
AGRAVANTE	**:**	**RAFAEL BELLINCANTA (Absolutamente Incapaz (Art. 3º, II e III CC))**
	:	**MARTA BELLINCANTA DOS SANTOS (Pais)**
ADVOGADO	**:**	**LEANDRO GUILHERME SIGNORINI**
AGRAVADO	**:**	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
MPF	**:**	**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Caxias do Sul - RS que, em ação objetivando o restabelecimento de **benefício assistencial** à pessoa incapaz e a declaração de inexigibilidade de restituição dos valores recebidos a tal título, indeferiu o pedido de **antecipação de tutela** nos seguintes termos (evento 9, DESPADEC1):

> *"Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita requerido pelo demandante, nomeando como assistentes judiciários os procuradores qualificados no instrumento de mandato.*
> *Trata-se de processo em que o autor pretende obter **antecipação de tutela** para que seja restabelecido seu **benefício assistencial** cancelado e impedida a cobrança por parte do INSS dos valores até então recebidos a esse título. Aduz que o benefício foi cancelado pelo INSS em virtude de reavaliação financeira e constatação de que a mãe do autor recebe pensão por morte desde 2005. Salienta "que a pensão por morte que a mãe do autor recebe é de renda mínima, ou seja, um salário mínimo (fls.46/47 do Processo Administrativo) e esta não deveria ser considerada no cômputo de renda familiar. Ademais deveriam ser excluídos todos os gastos com remédios, alimentação, moradia, água, gás e energia elétrica entre outros, do cômputo da renda familiar para uma correta análise" (fl. 4). Refere que a assistente social que atende a família desde 2013 manifestou-se favorável à manutenção do benefício.*
> *É o relatório.*
> *Com efeito, analisando os autos, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses permissivas da antecipação dos efeitos da tutela. Isso porque tal dispositivo foi criado para atender às hipóteses em que o direito pleiteado seja cristalino, não demandando maiores indagações, uma vez que se trata de antecipação dos efeitos do resultado final do processo, antecipando-se a própria prestação resultante da sentença. E somente nas hipóteses em que não haja maiores dúvidas acerca do direito pleiteado é que se pode deferir tal antecipação. A redação do caput do artigo 273 do CPC é clara neste sentido, ao afirmar que "o juiz poderá (...) antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, (...)", o que, ao menos por ocasião desta análise preliminar, não se verifica no caso ora em apreço.*
> *Além disso, cumpre não olvidar que os atos administrativos gozam de presunção de*

legitimidade, o que significa afirmar que "se a Administração Pública se submete à lei, presume-se, até prova em contrário, que todos os seus atos sejam verdadeiros e praticados com observância das normas legais pertinentes" (in DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 4. Ed., São Paulo, Atlas, 1994, p. 65).]
Assim sendo, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Intime-se a parte autora da presente decisão, bem como para, no derradeiro prazo de 30 (trinta) dias, regularizar sua representação processual, por meio da juntada de procuração por instrumento público.
Cite-se.
Adriane Batissti,
Juíza Federal"

Inconformado, o Agravante relata, em síntese, que é titular de **benefício assistencial** desde 19/11/1998 em decorrência de doença mental grave, mas que em março de 2015 recebeu comunicação do INSS de que seu benefício seria cessado por ter sido constatado o descumprimento do requisito econômico já que sua mãe, Marta Bellincanta, passou a receber uma pensão por morte desde 30/10/2005.

Alega que *"É importante ressaltar Excelência que a pensão por morte que a agravante recebe é de renda mínima e não é aposentada, ou seja, um salário mínimo (fls.5.6 do "PROCADM10" - evento nº 01) e esta não deveria ser considerada no cômputo de renda familiar, ou ao menos reduzida excluindo-se todos os gastos com aluguel, remédios, alimentação, moradia, água, gás e energia elétrica entre outros, do cômputo da renda familiar para uma correta análise ("LAUD14"-evento nº 01 do processo originário)."* e que *"Outro fato importante é que Rafael necessita de acompanhamento permanente de outra pessoa, tem crises epiléticas, utiliza fraldas e toma vários medicamentos. Marta Bellincanta também faz uso de medicamentos conforme comprovam os atestados anexados a este processo."*

Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento do agravo para que seja determinado o imediato restabelecimento do benefício.

O **recurso** foi recebido e deferida a antecipação dos efeitos da tutela rcursal.

É o relatório.

VOTO

Por ocasião da decisão inicial assim me manifestei:

"(...)

É o breve relatório. Decido.

*Os requisitos necessários à **antecipação de tutela** são expressos em lei, quais sejam: existência de prova inequívoca, hábil a produzir um juízo de **verossimilhança** das alegações, e fundado receio de **dano irreparável ou de difícil reparação**.*

Examinando os documentos que formam o presente instrumento, verifico que a causa do cancelamento administrativo do benefício cingiu-se ao desatendimento, pela família, do requisito econômico de renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo, não tendo havido qualquer questionamento acerca da incapacidade do autor (evento 1, PROCADM23, pg. 62).

À época em que concedido o benefício, em relação ao critério econômico, o art. 20, § 3º, da Lei n.º 8.742/1993, estabelecia que se considerava hipossuficiente a pessoa com deficiência ou idoso cuja família possuísse renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, ao apreciar ***recurso*** *especial representativo de controvérsia,* ***relativizou o critério estabelecido pelo referido dispositivo legal****. Entendeu que, diante do compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana, "a limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo" (REsp n. 1.112.557/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, j. 28/10/2009, DJ 20/11/2009).*

Além disso, o STJ, órgão ao qual compete a uniformização da interpretação da lei federal em nosso sistema, acrescentou, no julgado citado, que "em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de prova da condição de miserabilidade do beneficiado".

Como se percebe, o entendimento da Corte Superior consolidou-se no sentido de que ***é possível a aferição da miserabilidade do deficiente ou do idoso por outros meios****, ainda que não observado estritamente o critério da renda familiar per capita previsto no § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/1993.*

Nesse sentido, ***tenho adotado posição de flexibilizar os critérios de reconhecimento da miserabilidade****, merecendo apenas adequação de fundamento frente à recente deliberação do Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, ao analisar os recursos extraordinários 567.985 e 580.963, ambos submetidos à repercussão geral,* ***reconheceu a inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/1993 - LOAS, assim como do art. 34 da Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso****.*

Com efeito, reconhecida a inconstitucionalidade do critério econômico objetivo em regime de repercussão geral, ***cabe ao julgador, na análise do caso concreto, aferir o estado de miserabilidade da parte autora e de sua família, sendo o caso, a justificar a concessão do benefício assistencial****. Cabe registrar que esta Corte - Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ainda que por outros fundamentos, vinha adotando uma maior flexibilização nos casos em que a renda per capita superava o limite estabelecido no art. 20, § 3º, da LOAS, agora dispensável enquanto parâmetro objetivo de renda familiar.*

Em conclusão, ***o benefício assistencial destina-se àquelas pessoas que se encontram em situação de elevada pobreza****, por não possuírem meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, ainda que a renda familiar per capita venha a ser considerada como meio de prova desta situação.*

No caso concreto, o benefício foi cancelado sem amparo em estudo socioeconômico atestando a modificação da condição financeira da família ou a desnecessidade do benefício para a sobrevivência do grupo familiar. Se deu, isto sim, de forma automática pela simples constatação

de superação da renda per capita de 1/4 do salário mínimo.

Logo, a verossimilhança da pretensão deduzdida pelo Autor exsurge não apenas da inconstitucionalidade do critério de miserabilidade adotado pelo INSS mas, inclusive, das particularidades da situação em exame, com destaque para o laudo social atual constante do evento 1 (LAU14), que a despeito de ter sido produzido unilateralmente, não foi objeto de impugnação pelo réu em sua contestação.

Assim, e ao menos por ocasião de um exame preliminar, identifico a verossimilhança acerca da vulnerabilidade econômica do autor que há mais de 15 anos vem tendo sua subsistência amparada pelo ***benefício assistencial*** *e da ilegalidade do ato administrativo que declarou o desatendimento pelo autor do critério sócio-econômico necessário para fazer jus ao benefício vez que pautado em critério julgado inconstitucional pelo STF (****Recurso*** *Extraordinário 580.963/PR).*

Ante o exposto, ***defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o restabelecimento do benefício assistencial ao Agravante em até 15 dias.***

Comunique-se ao Juízo de origem.

Vista ao Agravado para responder.

Intimem-se."

Não vejo razão agora para modificar tal entendimento.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7757604v3** e, se solicitado, do código CRC **18F1337B**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Rogerio Favreto
Data e Hora:	12/11/2015 13:26

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 10/11/2015

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5028197-03.2015.4.04.0000/RS
ORIGEM: RS 50059980620154047107

RELATOR : Des. Federal ROGERIO FAVRETO

PRESIDENTE	:	Rogerio Favreto
PROCURADOR	:	Dr. Alexandre Amaral Gavronski
AGRAVANTE	:	RAFAEL BELLINCANTA (Absolutamente Incapaz (Art. 3º, II e III CC))
	:	MARTA BELLINCANTA DOS SANTOS (Pais)
ADVOGADO	:	LEANDRO GUILHERME SIGNORINI
AGRAVADO	:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
MPF	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 10/11/2015, na seqüência 243, disponibilizada no DE de 20/10/2015, da qual foi intimado(a) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 5ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RELATOR ACÓRDÃO	:	Des. Federal ROGERIO FAVRETO
VOTANTE(S)	:	Des. Federal ROGERIO FAVRETO
	:	Juiz Federal LUIZ ANTONIO BONAT
	:	Juiz Federal HERMES S DA CONCEIÇÃO JR

Lídice Peña Thomaz
Secretária de Turma

Documento eletrônico assinado por **Lídice Peña Thomaz, Secretária de Turma**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7963279v1** e, se solicitado, do código CRC **AC364AC1**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Lídice Peña Thomaz
Data e Hora:	11/11/2015 12:00